

1500752-17.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de a quo explicita, de forma clara e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Jardim Francisco Morato, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500752-17.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL DOS SANTOS ROCHA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Data da Audiência:

20/04/2022

Réu Preso

Aos 20 de abril de 2022, às 14 horas e 45 minutos, nesta cidade de Francisco Morato, na sala de audiências do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Francisco Morato, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dra. Renata Marques de Jesus, comigo escrevente abaixo assinado. Presente representante do Ministério Público Dr. João Paulo Robortella, foi aberta audiência de instrução e interrogatório (na forma virtual, conforme o art. 17, da Resolução n.º 329/2020 do CNJ, e o item 13, do Comunicado CG 284/2020), nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais e apregoadas as partes, restaram: AUSENTE o réu GABRIEL DOS SANTOS ROCHA e PRESENTE o réu WEDSON CLEMENTE PEREIRA, representados pelos respectivos advogados Dra. Catia Santos Nascimento de Santana e Dr. Gerson Goncalves Germano. Presentes as testemunhas Alex Fabiano Panzani e Maciel Gomes da Silva, as quais foram ouvidas. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito foi dito: Ante a não localização do indiciado Gabriel, desmembre-se os autos, servindo esta audiência como produção antecipada de prova em relação a ele. Terminadas as inquirições, foi colhido o interrogatório do(s) réu(s) Wedson. O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) através do Microsoft Teams, arquivado(s) na plataforma One Drive e não será(ão) transcrito(s) em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito foi dito: Considerando que as partes não postularam novas

diligências, declaro encerrada a instrução. Passo a palavra ao representante do Ministério Público para alegações finais, seguido pela Defesa de Wedson. Pelo Ministério Público foi dito: "MM. Juiz(a), GABRIEL DOS SANTOS ROCHA e WEDSON CLEMENTE PEREIRA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) observado o disposto na Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). Os réus foram notificados por edital (fls. 155/160). A denúncia contra WEDSON foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 274/275), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados. O feito foi suspenso em relação ao corréu GABRIEL (fls. 170), ante sua impossibilidade de localização, sendo, no entanto, determinado que a audiência de instrução será aproveitada para este acusado a título de antecipação de prova. Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 271/273 e 299). Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, procedendo-se ao interrogatório do réu. Assim, vencida a fase instrutória, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, laudo de constatação preliminar de fls. 18/20 e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 167/169). A autoria é inequívoca, comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral produzida. A testemunha Maciel Gomes da Silva, policial militar, relatou que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, no momento em que avistou dois indivíduos em atitude suspeita, os quais interagiam entre si e aparentavam estar juntos. Ao avistarem a viatura, eles correram juntos e pularam um córrego, mas foram detidos. Na posse de WEDSON foram encontradas diversas porções de drogas, além de certa quantia em dinheiro. Com o outro indivíduo, GABRIEL nada foi encontrado. Indagados informalmente, ambos admitiram a prática do tráfico de drogas, sendo que GABRIEL disse que estava auxiliando na venda dos entorpecentes. No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar Alex Fabiano Panzani. Com efeito, as testemunhas corroboraram os fatos descritos na denúncia. Em seu interrogatório, o corréu WEDSON confessou a prática do crime, inclusive confirmando a participação do corréu GABRIEL. Ressalte-se que os policiais, na qualidade de agentes públicos, gozam de fé pública e não há nenhum elemento nos autos a abalar sua credibilidade. Pelo contrário: tais depoimentos se mostraram em consonância com o restante da prova produzida. Seus testemunhos, portanto, possuem pleno valor probatório, tanto que estão sujeitos a crime de falso testemunho como qualquer cidadão, conforme orientação da jurisprudência: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014, os destaques não são do original); PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de a quo explicita, de forma clara e fundamentada, os elementos de sua convicção. Na hipótese, a Corte de origem enfrentou todas as omissões apontadas nos aclaratórios opostos pela defesa. 2. O exame da pretensão recursal no sentido da ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a conduta de tráfico e associação para o tráfico, implica a necessidade de revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos. Incidência da Súmula n. 7 deste

Superior Tribunal de Justiça. 3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014, os destaques não são do original). Ademais, já asseverou o Desembargador José Renato Nalini: "é valioso o depoimento de policiais em hipóteses como a presente. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida como a narrada nestes autos" (TJSP - Autos de Apelação nº 141.299-3/3 - Segunda Câmara - v.u.). O propósito da traficância é certo, haja vista: (1) a natureza, diversidade e a considerável quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas; (2) a forma de acondicionamento das substâncias em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo de terceiros; (3) a quantia em dinheiro apreendida, a qual era produto da venda ilegal de drogas; (4) o local da abordagem, já conhecido como ponto de tráfico; (5) a confissão do acusado. Assim, comprovou-se de forma inequívoca a prática do delito em apreço, bem como, a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade dos fatos imputados ao acusado, impondo-se, desta feita, a sua condenação. Passa-se, então à análise da pena a ser aplicada. Na primeira fase de dosimetria da pena, atentando-se aos parâmetros do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, ante a diversidade das drogas apreendidas (3 diferentes espécies), dentro delas o crack, de altíssima lesividade, que possui rápido efeito e grande potencial de vício, cuja traficância vem destruindo famílias e causando sérias consequências à sociedade. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Incide, ainda, a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não se vislumbra óbice à aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, desde que em seu grau mínimo em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como em função das passagens pretéritas de WEDSON por tráfico de drogas na Vara da Infância e Juventude (fls. 45/46). O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, a rigor do que dispõe o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). Vedada a conversão em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, valendo destacar que se trata de delito equiparado a hediondo, a demandar maior rigor em sua reprimenda. Ante o exposto, o Ministério Público requer seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação de WEDSON CLEMENTE PEREIRA, nos exatos termos da denúncia. Com o trânsito em julgado, requer-se o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, emitindo-se a respectiva guia, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06". Pela Defesa de Wedson foram apresentadas alegações finais orais. "MM. Juiz(a),

"As alegações finais foram gravadas através do Microsoft Teams, arquivadas na plataforma One Drive e não serão transcritos em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Em seguida foi proferida a sentença pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito: "Vistos. WEDSON CLEMENTE PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado juntamente com GABRIEL DOS SANTOS ROCHA como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de abril de 2020, por volta das 11h00, na Rua Paulo VI, altura do nº 432, Jd. N. Senhora Aparecida, cidade e Comarca de Francisco Morato, agindo em concurso entre si, traziam consigo, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) porções de "maconha" (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 31,8g (trinta e uma gramas e oito decigramas); 31 (trinta e uma) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 17,5g (dezesete gramas e cinco decigramas); e 41 (quarenta e uma) porções de crack, com peso líquido aproximado de 3,9g (três gramas e nove decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 3/5). Em audiência de custódia foi deferido o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (fls. 63/64). Os réus não foram localizados e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 170), sendo decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 195/196). O corréu Wedson foi preso (fls. 247/248), constituiu patrono (fls. 268) e apresentou defesa prévia (fls. 271/273). O feito permaneceu suspenso em relação ao corréu Gabriel, impondo-se a unificação da audiência de instrução de Wedson, aproveitando-a como antecipação de prova para Gabriel, que foi assistido por advogado nomeado (fls. 290), que apresentou defesa prévia às fls. 299. O feito foi desmembrado em relação ao corréu Gabriel, não localizado. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado. Mídia arquivada. Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, nos termos da denúncia, com imposição de regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como aplicação do redutor máximo previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. É o relatório. Fundamento e decido. À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar. A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 6/12), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação provisória (fls. 18/20), além do exame químico-toxicológico de fls. 124/126, que constatou as presenças de tetrahydrocannabinol (THC) e de cocaína nas amostras analisadas. A autoria também é certa, corroborada pela própria confissão. Durante a fase extrajudicial o corréu Wedson confessou a prática do delito, narrando que estava exercendo a venda de entorpecentes e também a função de olheiro em conjunto com Gabriel (fls. 11). Em juízo, contando estar com 21 anos de idade, fazia bico em construção, com renda de R\$ 70,00 por dia, não tem filhos menores de idade, mora em casa própria, tem passagem por ato infracional por tráfico e não cumpriu medida, mantendo sua versão anterior, declarou que de fato estava com o Gabriel no tráfico. Era o primeiro dia e iria ganhar entre R\$ 100 e 200,00. Estava com as drogas e Gabriel dava o apoio. O dinheiro apreendido era fruto. São trigêmeos: Wydson, Wdson e Wedson. A testemunha Alex Fabiano Panzani, policial militar que participou da ocorrência, afirmou que estava em patrulhamento de rotina e em uma viela avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em local já conhecido como ponto de tráfico. Os dois visualizaram a viatura e tentaram fugir. Lograram êxito em abordá-los. Com Wedson tinha uma pochete contendo entorpecentes e no bolso, da bermuda ou calça, a quantia de pouco mais de R\$ 100,00. Ambos foram indagados e confirmaram a traficância no local. Ganhavam de R\$ 150,00 a R\$ 200,00 por dia. Não conhecia os indivíduos antes dos fatos. Com o outro nada de ilícito foi encontrado, mas disse que estava em apoio ao outro também preso no local. Recordou-se do réu presente em audiência, apenas não sabendo precisar, em razão do tempo decorrido, se era ele quem estava com a pochete contendo as drogas. Na mesma esteira o depoimento do também policial militar Maciel Gomes da Silva, informando que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico. Dois correram e com um dele foi encontrado dentro da pochete uma quantia em droga, dinheiro e celular. "Geziel" disse que estava fazendo tráfico. O outro também confirmou a traficância. Não conhecia os envolvidos antes dos fatos. Não se recordou do réu presente em audiência. Esclareceu que os dois rapazes estavam juntos, bem próximos e passaram a mesma versão quando indagados. Um estava com a droga e com o outro nada foi localizado. Ambos correram juntos. Depois de abordados ambos confirmaram que estavam juntos. É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que o acusado e os policiais militares não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente. Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas

de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade: “É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011); “O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586); “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189); “Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP, RT 614/275); “Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso” (TJMG, RT 604/407). A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório. E, nada restou demonstrado acerca de eventual motivo que os policiais militares teriam para mentir em juízo, destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido: “PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câmara - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTCRIM 6/78). É preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos. Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas comuns ouvidas sob o

crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, corroborando a própria confissão, levando à certeza da autoria. Sendo assim, a variedade, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas, o fato de o local da apreensão ser conhecido dos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, corroborado pela própria confissão, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião. Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistentes em “trazer consigo” as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito: “Nunca

é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco). No mesmo sentido: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542); "Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia). Ressalta-se que a considerável quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam pretendida classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06): "DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09). E o fato de o acusado eventualmente afirmar que é usuário de droga, o que não se vislumbra, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante: "(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498); "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9ª Câmara Criminal, Ap. nº 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016); "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104). Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio. Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelo réu à figura típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena: Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No

mesmo sentido: "REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017). O réu é primário e não possui antecedentes criminais (fls. 44), contudo, na hipótese, foi localizado com "crack" e cocaína, entorpecentes de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitativa daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício. Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378). No mesmo sentido, defende Ricardo Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787). Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza. Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal/verifico presentes as circunstâncias atenuantes da confissão (artigo 65, III, "d", do Código Penal) e da menoridade (artigo 65, I, do Código Penal, fls. 11 e 221), razão pela qual retorno a reprimenda imposta ao seu mínimo, sendo nesta fase vedada a fixação abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ). No presente caso, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois se trata de uma benesse que deve ser aplicada em casos pontuais em que há pequeno potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado, o que, obviamente, não é o caso do réu. O referido § 4º prevê que o benefício será aplicado ao agente que, além de ser primário e portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça que a dedicação à atividade criminosa é óbice à aplicação da causa de redução de pena, independentemente do grau de comprometimento do agente com o

crime, ou da complexidade da estrutura da organização criminosa (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.357.182/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). Assim sendo, os elementos apurados, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução, especialmente considerando a existência de apuração de fatos por ato infracional equiparado ao delito de tráfico, o que foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório, portanto, idêntico ao aqui tratado. Aliando-se à expressiva variedade de entorpecentes encontrados, tendo como destinação certa a venda, tem-se que não se trata de traficante eventual ou de mera participação para sustento do próprio vício. Todas as provas e circunstâncias concretas demonstram que o acusado faz do tráfico seu meio de vida, mostrando-se incabível a aplicação do § 4º do artigo 33, da Lei De Drogas: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal. 2. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. A Corte local deixou de aplicar a minorante respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, que demonstraram que o paciente dedicava-se à atividade criminosa, excluindo a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 4. A ausência de comprovação de atividade lícita não pode, por si só, levar à conclusão imediata de dedicação à atividade ilícita. Todavia, o conjunto de circunstâncias consideradas pelo Tribunal de origem, de fato, sinaliza essa dedicação, sobretudo, por ser o paciente conhecido no meio policial devido a seu envolvimento no tráfico de entorpecentes, não se olvidando, ainda, da considerável quantidade de droga apreendida. 5. Desconstituir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demanda ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 421.925/SP, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso. "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgInt no HC 467.947/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe de 01/02/2019) – grifos nossos. "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Quanto a consideração de atos infracionais anteriores na dosimetria da pena, esta Corte é uníssona no sentido de que não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência. Entretanto, este Tribunal tem evoluído, entendendo que

os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas, sendo inclusive, fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. III - Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas. IV - Quanto ao regime prisional, a quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) - grifos nossos. "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRAFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL COMETIDO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do recorrente ter praticado ato infracional quando adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, se evidenciada a dedicação a atividades criminosas. Precedentes da Quinta Turma. 2. Entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial a teor do verbatim n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RESp 1653501/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 09/05/2017, data da Publicação DJe 17/05/2017) - grifos nossos. "HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza " e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada." (STJ, Quinta turma, HC 121509/SP, relator Ministro FELIX FISHER, data do julgamento 18/02/2010 e data da publicação DJe 29/3/2010). Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição. O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado. O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois pressupõe violência e grave ameaça à sociedade, principalmente por atingir a sua população mais jovem e vulnerável, aumentando os índices de criminalidade, desestruturando cada vez mais famílias e trazendo danos de toda sorte aos envolvidos, tendo o traficante a intenção de levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, não se pode olvidar a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente fechado: "TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; 6ª Câmara de Direito Criminal; AP

0057527-71.2011.8.26.0050; Relator Marco Antonio Marques da Silva, data do julgamento: 27/06/2013). Vale lembrar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (HC 111.840/ES), a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante. E, não sendo o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme justificado, não há que se falar em aplicação da determinação proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), que determinou a fixação do regime aberto em relação aos presos que "se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado)", estabelecendo, dentre outras determinações, que "aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena" (grifo nosso). As condições pessoais do réu não são idênticas às daqueles para os quais se determinou a concessão de regime inicial aberto não se mostrando socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Ainda que assim não fosse, impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena e também da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, o que justifica a não substituição da reprimenda (STJ, Quinta Turma, HC 24914/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 14/04/2013) : "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 11,2G DE COCAÍNA, 179,1G DE MACONHA E 554ML DE LANÇA-PERFUME - PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "j" - IMPOSSIBILIDADE - O NECESSÁRIO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS GARANTIU, POR INFELIZ VIA TRANSVERSA, O ANONIMATO E A IMPUNIDADE DE USUÁRIOS E TRAFICANTES - AGRAVANTE MANTIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A INDICAR QUE O ACUSADO, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO ADEQUADO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO" (TJSP; Apelação Criminal 1514354-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) - grifos nossos. Ademais, tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez. Pelo mesmo motivo e diante da persistência dos requisitos que mantiveram a prisão cautelar durante o curso do processo, o acusado não poderá recorrer em liberdade. Assim, deverá manter-se recolhido para poder recorrer, até porque seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na prisão em que se encontra, bem como guia de recolhimento provisória, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo da Execução competente. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar WEDSON CLEMENTE PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Em observância ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o réu encontra-se preso preventivamente a pouco mais de três meses (fls. 247/248), contudo, não há elementos nos autos - principalmente os subjetivos - para eventual colocação em regime mais benéfico, que fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais, a ele competindo proceder às adequações necessárias em caso de

existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a" e 111, ambos da Lei nº 7.210/84: "Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Com efeito, como acima fundamentado, respondeu ao processo preso, sendo certo que persistem e nesta sentença são reforçados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ, caso tal providência ainda não tenha sido adotada. Nos termos dos artigos 63, I e § 1º, e 64, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado (fls. 21), pois decorrente da prática do crime em questão. Observe-se o depósito às fls. 83. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais: "o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." - grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib). Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal, expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias." Pelo Ministério Público foi dito não ter interesse em recorrer. Assim, certifique-se de imediato o trânsito em julgado para a Acusação. A Defesa manifestou interesse em recorrer da sentença. Assim, recebo o Recurso interposto, devendo a i. Defesa apresentar as razões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Geziel Gomes Barbosa, Escrevente Téc. Judiciário, subscrevi.

MM. Juiz(a) de Direito:
Promotoria de Justiça:

Réu Wedson:

Réu Gabriel: ausente

Defesas:

Certifico e dou fé que o presente termo foi lido e achado conforme pelas partes presentes e por seus procuradores, os quais saem intimados de seu inteiro termo nada tendo a opor quanto ao seu conteúdo. Certifico ainda que, havendo sido presente o termo assinado eletronicamente pelo(a) MM.(a). Juiz(a) que à mesma presidiu, dispensa-se a assinatura das partes presentes. NADA MAIS. Eu, Geziel Gomes Barbosa, digitei.